

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제01절 행정심판의 대상적격>

[예상][12.01-2]부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

《【문제12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 시정권고를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음2) 乙이 행정청 B의 무반응에 대하여 제기할 수 있는 행정심판의 종류를 제시하고, 행정심판법상 부작위가 성립하기 위한 요건을 설명하라. 또한, 丙이 행정심판법에 따른 행정심판을 청구할 수 없는 예외적인 사유가 존재하는지 행정심판법 제3조를 중심으로 서술하라.》

<문제12.1의 물음2> 부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청 B가 인허가 신청에 대하여 상당한 기간 동안 아무런 처분을 하지 않는 부작위 상태에 있고, 丙은 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판 청구 가능 여부가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 부작위에 대한 의무이행심판의 요건과 행정심판법 제3조에 따른 행정심판 청구 제한 사유의 존재 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기할 수 있는 부작위에 대한 행정심판의 종류와 성립요건 및 丙이 행정심판을 청구할 수 없는 사유가 존재하는지 서술한다.

II. 부작위에 대한 행정심판의 종류 및 성립 요건

1. 행정심판의 종류

- 행정청의 부작위에 대하여 乙이 제기할 수 있는 행정심판은 크게 의무이행심판이다. 행정심판법 제5조 제3호에 따르면 의무이행심판은 행정청의 부당하거나 위법한 거부처분 또는 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 구하는 심판이다. 현행 행정심판법은 부작위위법확인심판을 별도로 두지 않고 의무이행심판으로 통합하여 운영하고 있다.

2. 부작위의 성립 요건

(1) 당사자의 신청

- 부작위가 성립하기 위해서는 먼저 법령에 근거하여 행정청에 대하여 특정한 처분을 구하는 당사자의 적법한 신청이 있어야 한다. 사안에서 乙이 행정청 B에게 인허가를 신청한 사실이 이에 해당한다.

(2) 행정청의 처분 의무

- 행정청에게 신청에 대하여 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재해야 한다. 이는 법령상 명시적인 의무뿐만 아니라 해석상 응답 의무가 인정되는 경우도 포함한다.

(3) 상당한 기간의 경과

- 행정청이 신청을 수리한 후 사회통념상 해당 처분을 하기에 충분한 상당한 기간이 경과하였어야 한다. 사안에서도 상당한 기간이 경과하였음이 명시되어 있다.

(4) 행정청의 무반응

- 행정청이 인가·허가 등의 긍정적 처분뿐만 아니라 거부처분과 같은 부정적 처분조차 하지 않은 상태여야 한다. 만약 거부처분을 하였다면 이는 부작위가 아니라 거부처분 취소심판이나 의무이행심판의 대상이 된다.

III. 행정심판 청구의 예외적 사유 [행정심판법 제3조]

1. 행정심판법 제3조의 취지

- 행정심판법 제3조 제1항은 모든 처분과 부작위에 대하여 행정심판을 제기할 수 있음을 원칙으로 하되, 사안의 성질상 행정심판법에 따른 심판 절차를 거치는 것이 부적절하거나 특별한 불복 절차가 마련되어 있는 경우에는 예외를 인정하고 있다.

2. 행정심판법 적용 제외 대상 [제3조 제2항]

- 행정심판법 제3조 제2항은 대통령의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정심판을 제기할 수 없다고 규정한다. 그러나 丙의 사례는 중앙선거관리위원회 위원장의 처분이므로 이에 해당하지 않는다.

3. 다른 법률에 따른 특별한 불복 절차

- 특정 기관의 행위에 대하여는 헌법적 지위나 절차의 특수성을 고려하여 행정심판법에 따른 행정심판 대신 별도의 특별행정심판이나 소송 절차를 허용하는 경우가 있다.

(1) 선거관리위원회 처분의 특수성

- 중앙선거관리위원회 위원장의 처분은 그 기관의 독립성과 전문성을 고려할 때 일반 행정심판위원회의 심리 대상으로 삼기에 부적절할 수 있다.

(2) 丙의 사례에 대한 적용

- 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분과 같은 인사에 관한 사항은 국가공무원법 등에 따라 소청심사라는 특별한 행정심판 절차를 거쳐야 하거나, 기관의 특성상 행정심판법의 일반적 절차가 배제될 수 있다. 특히, 행정심판법 제3조 제1항은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 예외로 두고 있는데, 선거관리위원회 위원장의 행위 등 헌법기관의 처분에 대해서는 해당 기관 내부에 설치된 위원회나 특별법에 따른 절차를 따르도록 규정된 경우가 많으므로 丙은 행정심판법상의 일반 행정심판을 청구할 수 없는 예외적 상황에 처할 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 구제 수단

- 乙은 행정청 B의 인허가 신청에 대한 무반응에 대하여 의무이행심판을 제기할 수 있다. 사안은 乙의 신청이 있었고, 상당한 기간이 지났으며, 행정청 B가 아무런 응답을 하지 않고 있으므로 행정심판법상 부작위 요건을 모두 충족한다. 따라서 乙은 행정심판위원회에 처분을 이행할 것을 구하는 심판을 청구할 수 있다.

2. 丙의 행정심판 청구 가능성 검토

- 丙이 다투고자 하는 중앙선거관리위원회 위원장의 처분은 행정심판법 제3조 제1항의 예외 사유에 해당할 가능성이 매우 높다. 헌법기관인 선거관리위원회의 처분은 그 독립성을 존중하여 일반 행정심판위원회의 감독을 받지 않으며, 소청심사와 같은 별도의 행정심판 절차가 마련되어 있거나 직접 행정소송으로 다투어야 할 사안에 해당하므로 丙이 행정심판법에 따른 일반 행정심판을 청구하는 것은 부적법할 것으로 판단된다.

V. 결론

- 乙은 행정청 B의 부작위에 대하여 의무이행심판을 통해 구제받을 수 있으며, 이는 행정청의 처분 의무와 상당 기간의 무응답이라는 부작위 요건을 충족하였기 때문이다. 반면 丙의 경우 처분청이 중앙선거관리위원회 위원장이라는 점과 파면이라는 인사 처분의 특성상, 행정심판법 제3조 제1항이 규정하는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 등에 해당하여 일반 행정심판법에 따른 심판 청구는 허용되지 않을 것이다. 이러한 법리는 행정청의 무분응에 대한 실효적 구제 수단을 제공함과 동시에, 헌법상 독립기관이나 대통령의 처분 등에 대해서는 일반적 심판 절차의 예외를 설정함으로써 권력분립과 행정의 특수성을 조화시키려는 취지를 담고 있다.